



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב אבא הלל 88 רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד יואב גותי
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבע: אליהו בושרי
ע"י ב"כ עוה"ד אילן לקפיש
מרחוב אנה פרנק 15, רמת גן 52526

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב אבא הלל 88 רמת גן הבנוי על חלקה 451 בגוש 6205 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המוסכם.

התובעת הינה נציגות הבית.

הנתבע הינו בעלים של תת חלקה 1 בבית המשמשת כקיוסק בקומת הקרקע (להלן: "החנות").

לטענת התובעת לנתבע חוב מיסי נציגות בסך של 8,342.94 ₪ בגין התקופה שמשנת 2004 ועד 2012. לבד מחיובו בתשלום סכום החוב נתבקש גם צו המורה על חיובו לשלם מיסי נציגות באופן שוטף לרבות קביעת סנקציה בהעדר תשלום. בנוסף נטען כי הנתבע השתלט על רחבה מרוצפת המהווה רכוש משותף, הציב בה כיסאות ושולחנות ומכונות ממכר ואף תחם אותה ביריעות פלסטיק תוך סיפוחה בפועל לשטח החנות. לפיכך נתבקש צו המורה לנתבע לסלק את ידו מן הרחבה, להסיר את יריעות הפלסטיק וכל ציוד שהתקין בה ולהשיבה לשימוש כלל בעלי הדירות. בנוסף התבקש חיוב הנתבע בתשלום פיצוי בגין השימוש ולחילופין פיצול סעדים בהקשר זה.

הנתבע טוען בכתב ההגנה כי יש לסלק את התביעה מחמת התיישנות ובדעתו גם לתבוע החזר בגין כספים ששילם ביתר לקופת הנציגות. מדובר בנציגות חדשה אשר מתנערת מהסכמות וסיכומים שהיו עם קודמתה לפיהן, במשך 17 שנים, הנתבע שילם ישירות לגנן הבית לצורך ניקוי המרפסת הצמודה לקיוסק והגינה הצמודה לה, חלף תשלום מיסי הנציגות. משכך, במשך כל השנים שילם הנתבע יותר מאשר חלקו הנתבע בהליך דנן וממילא הרבה יותר מאשר חלקו האמיתי בתשלום מיסי נציגות אשר צריך לעמוד על סך של 29 ₪ לחודש בלבד. הרחבה שליד החנות משמשת את החנות בלבד מאז הקמת הבית ורכיב תביעה בהקשר זה התיישן. הרחבה נבנתה במקור והיא עודנה חלק אינטגרלי מהחנות כאשר הכניסה והיציאה אליה היא דרך החנות בלבד. תמיד היו ברחבה שולחנות וכסאות ובאי העסק, במשך עשרות שנים, ישבו באותה הרחבה, לרבות, בעלי דירות בבית. לא נעשה כל שינוי ברחבה עשרות שנים והנתבע הוא זה אשר מתחזק אותה באופן בלעדי. לעסק קיים רישיון כדין ולא נשמעה כל תלונה מצד דיירים או הנציגות בנוגע לשימוש ברחבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

תביעת חוב מיסי נציגות

חוב מיסי נציגות הינו תביעה כספית רגילה "בשאינו מקרקעין" ומשכך, בהתאם להוראות סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, התובענה מתיישנת בחלוף 7 שנים מהיווצרות עילת התביעה. בהתאם להוראות הדין מרוץ ההתיישנות נעצר רק עם הגשת תביעה. משכך, כל תביעת חוב בגין תקופה הקודמת ל- 7 שנים לפני יום הגשת התביעה (12.11.12) התיישנה וניתן למחוק, על הסף, את החוב הנטען לשנים 2004-2005.

אין מחלוקת כי הנתבע לא שילם ואינו משלם את מיסי נציגות לידי הנציגות - טענתו של הנתבע היא כי במשך השנים נהג על פי הסדר עם הנציגות הקודמת לפיה חלף תשלום מיסי נציגות הוא משלם את חלקו ישירות לגגן הבית לשם ניקיון הרחבה והגינה שליד החנות. לטענה זו נשוב עוד להלן. אולם, בעצם טענת הנתבע מגולמת, למעשה, הודאה בדבר גובה מיסי נציגות, אף גבוהים מאשר אלו הנתבעים בהליך דגן - לשיטת הנתבע הוא שילם למנקה (בהסכמה) סך של 100 ₪ לחודש חלף תשלום מיסי הנציגות החלים עליו שעה שהנציגות תובעת מן הנתבע תשלום בסך של 70 ₪ בלבד.

הוכח בפני כי מאז ומתמיד שילמו כל בעלי הדירות בבית את מיסי הנציגות בחלקים שווים. כך העידו בעלי דירות וחברי נציגות בעבר ובהווה – עידן סער (חבר נציגות בשנים 2010-2012) מעיד "מכל אחד גביתי 70 ₪ בצורה שווה לכל בעל דירה. תחזוקה גם כן בצורה שווה אם יש סתימה או משהו כזה" (עמוד 7 שורות 6-7). כך הוא מעיד גם בנוגע לתקופת חברותה של הגב' רוזן בנציגות (שנפטרה בינתיים) - "אני יודע שבבניין מאז שבאתי לגור שם בשנת 2003, גם אצל גברת חוה רוזן לפני כן, כל הדירות שילמו באופן שווה, לא משנה הגודל. זו הייתה החלטה לפחות של חוה רוזן שהייתה ועד אספה כספים בצורה שוויונית" (עמוד 7 שורות 8-10). כך גם מעידה הגב' גותי – "אני יודעת על הוראת החוק אבל בבניין הזה הייתה החלטה שמשלמים באופן שווה. אין לי את ההחלטה. זה מיסי ועד שנגבו במשך השנים באותה מתכונת" (עמוד 16 שורות 4-8). כך גם עולה מפנקסי הקבלות שהוצגו (נספח י' לתצהיר גותי).

הוכח בפני כי הנתבע לא טען על כי גובה מיסי הנציגות הינו שלא בהתאם להוראות הדין ולראשונה העלה טענה זו רק במסגרת ניהול ההליך דגן. ויודגש, מעדותו של הנתבע עולה כי הוא "שילם" את מיסי הנציגות למנקה בהסכמה ומתוך ידיעה שהוא משלם יותר מאשר חלקו (עמוד 29 שורות 13-14). גם בעדותו בהליך אין בידו תאריך מתי גילה לכאורה כי הוא משלם יותר מאשר חלקו, ולמעשה אין כל טענה בדבר דרישה לתשלום בהתאם להוראות הדין (עמוד 30 שורות 1-4). ההלכה קובעת בהקשר זה כי הנתבע אינו יכול לדרוש השבה רטרואקטיבית של כספים אשר שולמו על ידו בהסכמה, אלא אך מן המועד בו ביקש לחזור לחלוקת ההוצאות על פי התקנון המוסכם (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי - ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (טרם פורסם) וכן א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331)). לאור האמור הרי שהטענה גם איננה יכולה לשמש כטענת הגנה מפני תביעה בגין חוב מיסי נציגות שלא שולם (בכל הנוגע לתקופה שבה לא נטען דבר בנוגע לחיוב שלא בהתאם להוראות הדין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עתה, אם כן, עלינו לבחון האם עלה בידו של הנתבע להוכיח קיומו של הסדר עם הנציגות בנוגע לתשלום מיסי הנציגות באמצעות תשלום ישירות למנקה ואם כן, האם הוכח ביצוע התשלום כאמור.

לאחר שקלול מכלול הראיות בתיק זה הרי שלא עלה בידי הנתבע להוכיח קיומו של ההסדר הנטען.

לבד מעדותו של הנתבע אין כל ראיה תומכת בהקשר זה – לא במסמכי הנציגות, לא בפרוטוקולים של אסיפה כללית ולא בעדות של מי מבעלי הדירות בבית. אין כל מסמך המאשר את קיומו של ההסדר האמור כפי שמעיד הנתבע בעצמו (עמוד 29 שורה 21). דווקא מי שהנתבע טען כי יוכל לתמוך את גרסתו, בנה של הגב' רוזן (ר' עמוד 1 שורות 25-26), העיד כי "לא ידעתי על ההסדר ולא ידעתי שיש הסדר. ש.ת. ההסדר הזה שמעתי עליו פעם ראשונה כשאסתר עשתה אסיפת דיירים ואז היא הקריאה מי חייב כספים ואז אלי אמר פעם ראשונה שהוא משלם לאיברהים. ש.ת. אני לא ידעתי על ההסדר" (עמוד 10 שורות 23-26). הטענה בדבר העדרו של הסדר נתמכת גם בעדותו של מר סער בנוגע לתקופה שבה הגב' רוזן עוד ניהלה את נציגות הבית – "גם לפי התצהיר וגם שגב' רוזן הייתה בחיים אני עזרתי לה לגבות את המיסים. דבר ראשון התלונות של גב' רוזן באוזניי היו על כך שהוא לא משתתף במיסי ועד ולא משתתף בהוצאות השוטפות של הבניין. זה היה חמור מאוד בעיניי והיא רצתה שיעשו עם זה משהו. לגבי הפניות שלי, אז פניתי אליו מספר פעמים והוא סירב לשלם" (עמוד 8 שורות 1-4) ובתקופה שלאחר מכן – "הוא נתן גם את ההסבר של המנקה ואמרתי לו שזה לא מקובל עלינו. לא ראינו שום קבלה ושום דבר" (עמוד 8 שורות 7-8).

למעלה מכך, על פי העובדות שהוכחו בפני הרי שעבודתו של המנקה עבור הנתבע, אף אם זה משלם לו תשלום כלשהו, איננה עבור נציגות הבית או להחזקת הרכוש המשותף.

ראשית, הוכח כי הנציגות מתחזקת את הרכוש המשותף לרבות כל שטח הגינה והרכוש המשותף בבית (עמוד 7 שורות 17-20 וכן עמוד 15 שורות 22-28).

שנית, עלות החזקת הרכוש המשותף בכללותו על ידי הגנן מסתכמת בתשלום בסך של כ- 250 ₪. אין כל הגיון בתשלום כה גבוה, בסך של 100 ₪ כנטען, עבור החזקה לכאורה של חלק קטן בלבד מהרכוש המשותף.

שלישית, מעדויות הנתבע עולה כי עבודת הגנן קשורה באופן ישיר לשימוש הנעשה על ידי הנתבע ברכוש המשותף – כך עולה מעדות קשיוב (עמוד 17 שורות 3-4) ובהתאם גם מעדות הנתבע (עמוד 27 שורות 25-27 ובהמשך עמוד 29 שורות 22-24). אם מבצע הנתבע שימוש ספציפי וייחודי ברכוש המשותף (ונדון להלן בטיב שימושו זה) כיצד אחזקת הרכוש עקב שימוש שכזה יכולה להיות תחליף לתשלום מיסי הנציגות החלים עליו ? !

רביעית, התשלום נתון, כל כולו, לשיקול דעתו של הנתבע – "ככה בא לי לשלם לגנן כמה שאני רוצה, הוא מצ'פר אותי אני מצ'פר אותו. הוא בסדר הוא עושה את העבודה שלו טוב" (עמוד 30 שורות 5-6). כלומר, מדובר בעבודה המבוצעת באופן אישי עבור הנתבע ולא כצינור עבור נציגות הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חמישית, הנתבע לא פנה לנציגות בכל תלונה בדבר תפקוד המנקה לאורך עשרות השנים בהן, לכאורה, זה לא מילא את תפקידו כראוי (עמוד 29 שורות 18-19).

שישית, הגנן איברהים, אף שעודנו עובד עבור הנתבע, לא זומן לעדות על ידי הנתבע בהליך זה ללא כל הסבר. בעדותו של האחרון היה בודאי כדי לסייע בהוכחת טענתו של הנתבע בדבר ביצוע התשלום למר איברהים ובגין אילו עבודות. אי העדתו של מר איברהים עומדת לרועץ לנתבע בהליך דנן שעה שעליו הנטל להוכיח גרסתו בדבר ביצוע תשלום מיסי הנציגות לאורך השנים באמצעות תשלום ישיר לגנן. ויודגש, הנתבע היה מודע לכך כי עליו לזמן את מר איברהים לעדות ואף טען כי פנה אליו בבקשה להגיש תצהיר מטעמו (סעיף 5 לתצהירו). דא עקא, הוא לא נקט כל פעולה בהתאם להחלטת מיום 27.12.12 לשם זימונו של העד.

לאור האמור לעיל הרי שלא הוכח קיומו של הסדר בדבר תשלום מיסי הנציגות באמצעות תשלום למנקה וממילא לא הוכח כי תשלום זה נעשה עבור החזקת הרכוש המשותף או בהסכמה כלשהי של נציגות הבית.

לפיכך, יש מקום לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבע בגין חובות מיסי נציגות שוטפים לתקופה שמשנת 2006 ועד 2012.

בנסיבות דנן הרי שיש גם מקום לחייב את הנתבע בתשלום חלקו בהוצאות החריגות הנטענות (נספח יג' לתצהיר גותי), משהוכח כי כל בעלי הדירות, לבד מן הנתבע, נשאו בתשלום הוצאות חריגות אלו (ר' פנקסי הקבלות בנספח י' לתצהיר גותי). טענה זו וההוצאות האמורות לא נסתרו על ידי הנתבע.

על פי הטבלה שצורפה כנספח יג' לתצהיר גותי הרי שסכום החוב הנומינלי (להוציא השנים 2004 ו-2005 כאמור) עומד על סך של 6,140 ₪ ועל הנתבע לשלמו.

לסך החוב הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מתום כל שנה (בגין החוב המפורט לאותה שנה בנספח יג' לתצהיר גותי) ועד למועד הגשת כתב התביעה. לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע בתשלום ריבית בגין החוב שעד למועד הגשת התביעה. המדובר בחוב המשתרע לתקופה של למעלה מ-7 שנים. אף על פי כן הנציגות לא נקטה בכל הליך לגביית החוב האמור במשך כל אותם השנים. אין הצדקה בנסיבות אלו לחיוב בתשלום ריבית (להבדיל מהפרשי הצמדה) שאינו נועד לתת ביטוי לערך הכסף. החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד למועד התשלום בפועל יתווספו לסכומים הפרשי הצמדה וריבית כדין.

הקביעה כאמור לעיל הינה בגין החוב לעבר אותו צבר הנתבע לאורך השנים. אולם, כיום, משעה שהנתבע מתנגד לתשלום שוויוני של מיסי נציגות ועומד על גביית התשלום על פי התקנון המוסכם על פי זכותו (ר' תיק 92/10 נציגות הבית המשותף רחוב תנועת המרי 4 קרית אונו נ' שרה רודברג (פורסם בנבו)), מוטב תעשה התובעת ותסדיר את חלוקת התשלומים, החל משנת 2013, בהתאם להוראות הדין, בודאי בנוגע לחלקו של הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא מצאתי מקום לקבוע סנקציה בגין אי תשלום מיסי נציגות לעתיד. מדובר בחוב כספי רגיל שככל שיווצר יהיה על התובעת לנהל הליך פרטני לשם גבייתו.

תביעה לסילוק יד

הכלל הבסיסי הוא כי נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמו של התובע בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

ממסמכי רישום הבית המשותף (נספח ב' לתצהיר גותי) עולה במפורש כי השטח נושא המחלוקת דנן (להלן: "הרחבה") אינו נכלל כחלק מהחנות. סימון החנות בתשריט אינו כולל את שטח הרחבה. גם שטח החנות המפורט במסמכי רישום הבית המשותף אינו כולל חישוב של הרחבה אלא את קונטור החנות בלבד. אין כל הצמדות של חלקים מן הרכוש המשותף לאיזה מדירות הבית והוא מתנהל על פי התקנון המצוי. למעשה, גם הנתבע אינו חולק על כך כי הוא אינו בעלים של הרחבה, כפי שטען כבר בראשיתם של ההליכים דנן – "אנחנו לא אומרים שאנחנו הבעלים" (עמוד 1 שורה 13).

די בכך מבחינת התובעת כדי לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש, בפרט כאשר המדובר בהליך המתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פ"ד לח (4) 487). עתה עובר נטל ההוכחה לידי הנתבע - על הנתבע הנטל להוכיח טענותיו בדבר השימוש המותר ברחבה, הסכמות של בעלי הדירות לשימוש ומשמעות שימוש זה מבחינה משפטית (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)).

תחילה עלינו לבחון אם המדובר בנסיבות דנן בשימוש סביר ברכוש המשותף כרכוש משותף.

לאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית ישנה גם הסמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים - כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מתיבה; כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

הוכח בפני כי השימוש אותו עושה הנתבע ברחבה אינו בגדר שימוש סביר.

מדובר בשימוש הכולל תפיסת חזקה ייחודית בשטח הרחבה לצורך העמדת שולחנות וכסאות לשימוש באי החנות (עמוד 24 שורה 13). אומנם, לא נמנעת בפועל אפשרות הגישה של בעלי הדירות בבית לרחבה. אולם, שעה שהרחבה משמשת עבור באי החנות הרי שיכולת השימוש של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעלי הדירות לצורכיהם (שאינם מתיישבים בהכרח עם צורכי החנות) קטנה עד בלתי אפשרית. ראייה לשימוש בעלי הדירות כאמור ניתן למצוא בעדויות גותי (עמוד 13 שורה 14), רוזן (עמוד 9 שורות 2-7 ועמוד 11 שורות 6-7) ואף בעדות הגב' ירושלמי (עמוד 22 שורות 26-27). אין אפשרות כיום לשימוש שכזה. הוכח כי שימוש בעלי הדירות ברחבה כיום הינו, למעשה, רק כ"לקוחות" החנות (ר' למשל בעמוד 16 שורות 28-29, ובעמוד 17 שורות 20-21).

זאת ועוד. השימוש ברחבה כלל גם ביצוע פעולות בינוי - סגירת הרחבה ביריעות (תמונות בנספח ד' לתצהיר גותי), תליית שלטים (עמוד 25 שורות 7-8), התקנת מערכת תאורה שהשליטה בה מתוך החנות בלבד (עמוד 24 שורות 20-24), הדבקת ריזוף (עמוד 27 שורה 19) ולמעשה הרחבת חנות בפועל לשטח זה כאשר הכניסה לרחבה הינה רק דרך החנות או על ידי קפיצה מעל הגדר הבנויה (עמוד 26 שורות 8-9). פעולות אלו אין בזכותן של בעל דירה לבצע ברכוש המשותף באופן עצמאי (ר' ע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444).

שימוש כאמור הכולל אלמנטים ברורים של סיפוח שטח הרחבה בפועל, לא יכול להיות, מעצם טבעו, בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף. ויודגש, מעדות הנתבע עצמו עולה כי **הרחבה הינה חלק אינטגרלי לשיטתו מהחנות** ובלעדיה אין קיום לעסק בחנות - "אם לא הייתה רחבה בטח לא הייתי קונה ולא שוכר" (עמוד 26 שורה 30 ור' גם בסעיף 8.6 לתצהיר).

משכך, אין המדובר בנסיבות דנן בשימוש סביר ברכוש המשותף אלא בתפיסת חזקה ייחודית. אולם, אין בכך די בהליך דנן שכן הנתבע טוען כי מדובר בשימוש שנעשה (על ידי הנתבע וקודמו) לאורך שנים רבות. עתה עלינו לבחון משמעות סוגיה זו, עובדתית ומשפטית.

תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, בדומה להצמדה של רכוש משותף לדירה על פי סעיף 62 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), טעונה הסכמה של בעלי הדירות. בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לדיירים האחרים ברכוש המשותף כפי שנפסק בע"א 2525/92 גבי וקרני דאוכברגר נ' עיריית רמת גן פ"ד מז(5) 850: "...משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף', המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם..." (ר' גם רע"א 698/85 בן צור נ' נעים ששון מא(3) 144; י. ויסמן דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז, 1997) עמ' 455-454).

שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף, דורש אם כן הסכמה של כל יתר בעלי הדירות - ומהי אותה הסכמה נדרשת?

כבר נפסק בעבר כי הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קנייניות איננה חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה. הסכמה שכזו גם יכולה לחייב בעלי דירות אחרים שידעו על קיומה ונהגו על פי מציאות קיימת. הסכמה למתן רשות שימוש יכולה להילמד גם מכללל ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים. אולם, בכדי ליתן תוקף קנייני להסכמה הרי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע (ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד לו(3) 78; ע"א (מחוזי - ת"א) 1020/03 בבלייל ישראל נ' שטיינר יוסף (פורסם בנבו); ר' ע"א 9502/06 (מחוזי - י-ם) רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר (פורסם בנבו); ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210).

על מנת להסיק ויתור מהתנהגות הרי שזו חייבת להיות "ברורה וחד משמעית, ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה זמיר ז"ל נ' יעל דולב (שמיר) (פורסם בנבו)).

עוד נקבע כי משעה שניתנה ההסכמה, אין להתיר לבעל דירה שהסכים להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק (פרשת כליפא לעיל וכן ע"א 19/81 ביבי נ' הוברט פ"ד לז(2) 497; ע"א 31/70 כהן נ' שמאי פד"י כ(2) 388).

בנסיבות דנן לא הוכחה הסכמה פוזיטיבית של בעלי הדירות לשימוש המבוצע על ידי הנתבע ברחבה. אין ולו ראייה אחת בכתב התומכת בקיומה של הסכמה פוזיטיבית. למעשה, גם אין כל ראייה לקיומה של הסכמה פוזיטיבית בעל פה.

ראשית, כל טענתו של הנתבע מתבססת על העדר תלונות של בעלי הדירות ולא על קיומה של הסכמה פוזיטיבית כלשהי (עמוד 26 שורה 28 עד עמוד 27 שורה 3).

שנית, אין כל טענה של הנתבע כאילו הוא עצמו קיבל הסכמה כלשהי לשימוש. כל טענתו בהקשר זה הינה על הסכמות שניתנו לקודמו בזכויות, התבססות המהווה עדות שמיעה (ר' עמוד 26 שורות 1-2). זאת ועוד. הנתבע בחר שלא לצרף בהליך את הסכם השכירות או הסכם המכר אשר לכאורה אמורים היו לבסס את טענתו בדבר קיומה של הסכמה לשימוש שניתנה לקודמו בזכויות והמחאתה אליו. אין בעובדה כי חלפו שנים רבות מאז שכירת החנות על ידי הנתבע או מאז רכישת הזכויות בה, כדי להצדיק את העדרם של המסמכים האמורים, שעה שהנתבע יודע כי אין בידו זכויות קנייניות ברחבה וכל זכויותיו הנטענות מתבססות על אותן הסכמות לכאורה שקיבל קודמו. תמוהה גם כיצד דווקא נספח להסכם השכירות משנת 1986 נשמר בידי הנתבע (נספח ו' לתצהירו) אך לא המסמכים המהותיים יותר מאותה תקופה (הסכם השכירות) ומתקופה מאוחרת (הסכם המכר). בנסיבות אלו ניתן להסיק מסקנות ראייתיות כנגד הנתבע לפיהן בהסכמים האמורים לא היתה כל התייחסות לרחבה ובודאי שלא להסכמה כלשהי לשימוש בה (ר' בהקשר זה ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651).

שלישית, אף בעדותה של הגב' ירושלמי אין כדי לסייע לנתבע - אין היא מעידה על קיומה של הסכמה פוזיטיבית כלשהי (בכתב או בעל פה) של בעלי הדירות לשימוש ברחבה על ידי אביה. אעיר כבר עתה כי בעדותה גם נתגלו סתירות מהותיות. כך, בתצהירה היא מעידה על קיומה של זכות בלעדית ברחבה לבעלי החנות (סעיף 5 לתצהיר) אך בחקירתה הנגדית היא כבר מאשרת כי נעשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שימוש גם על ידי בעלי הדירות האחרים בבית (עמוד 22 שורות 26-27). כך, בתצהירה היא מאשרת כי הנתבע עושה שימוש באותה מתכונת כפי שעשו הוריה (סעיף 6 לתצהיר) אך בחקירתה היא כבר מעידה כי "לא היה מה שיש היום" (עמוד 22 שורות 18-21), כי שעות הפתיחה היו שונות (עמוד 23 שורות 12-13) וגם טיב העיסוק השתנה (עמוד 23 שורה 15).

מאידך, בנסיבות דנן הוכחה הסכמה מכללא לשימוש ברחבה.

הוכח כי נעשה שימוש ברחבה לאורך שנים על ידי בעלי ומחזיקי החנות – כך עולה מעדות הנתבע בנוגע לתקופת חזקתו בחנות ומעדות הגב' ירושלמי גם בנוגע לתקופת הבעלות של הוריה, משנת 1951 ועד 1985. כך גם עולה מעדויות התובעת בנוגע לשימוש מאז שנת 1985, קרי משכך זמן של כ- 30 שנה (עדות מר רוזן (עמוד 8 שורה 30 עד עמוד 9 שורה 1) ועדות הגב' גותי (עמוד 12 שורות 11-15)).

בנסיבות דנן הוכח כי לא הובעה התנגדות מפורשת של בעלי הדירות בבית לשימוש המבוצע ברחבה, לא בזמן שהחנות היתה בבעלות כהן (הבעלים הקודם), לא בתקופה בה החזיק הנתבע בחנות כשוכר ולא בתקופת הבעלות של הנתבע (ר' עדות הנתבע בעמוד 25 שורות 29-30).

למעשה, הפניה היחידה שיש בידי התובעת להציג (לבד מפניה שנערכה עובר לנקיטת ההליכים דנן) הינה משנת 2005 (נספח ו' לתצהיר גותי) וגם זו אין מחלוקת כי בסופו של יום לא נמסרה לידי הנתבע. עיון במכתב האמור מלמד על התנגדות לסגירת הרחבה (בויטרינה או יריעות פלסטיק) והצבת מתקנים. אולם, אין כל אזכור במכתב זה להתנגדות לשימוש המבוצע על ידי הנתבע ברחבה. אין בידי הגב' גותי גם כל הסבר מדוע בתקופה שמאז 1985, תחילת השימוש על ידי הנתבע, ועד שנת 2005 לא נעשתה כל פניה לנתבע בנוגע לרחבה (אף שהשימוש "הפריע"), וגם לא כל הסבר מדוע מאז ועד הגשת התביעה דנן חלפה תקופה נוספת של 7 שנים ללא מכתבי התראה או נקיטת הליכים משפטיים (ר' עמוד 13 שורה 1 ועמוד 14 שורה 3). גם מעדותו של מר רוזן לא עולה כל הסבר מניח את הדעת מדוע לא ננקטו, בין על ידו ובין על ידי בעלי הדירות בבית, הליכים משפטיים (אף לא מכתבי דרישה) בנוגע לשימוש ברחבה (עמוד 9 שורות 19-21).

בפרט אמורים הדברים כאשר הגב' גותי מעידה כי המדובר בשימוש מפריע (עמוד 12 שורה 28), כאשר המדובר בשימוש ידוע, גלוי וברור לעיני כל (לרבות בסגירה היריעות של הרחבה) ובשימוש הולך ומתגבר עם השנים. כך גם עולה מעדותו של מר רוזן (עמוד 9 שורות 1 ו-18).

ויוער, המכתב האמור, היחיד שהוצג, הינו מכתב אישי של הגב' גותי. לא הוצגה בהליך זה כל פניה מטעם נציגות הבית לדורותיה או החלטת אסיפה כללית בנוגע לשימוש הנתבע בחצר.

אי התנגדות של שכנים לשימוש, אף אם נעשה לאורך שנים, אין בה די כדי להוות הסכמה מודעת לשימוש או להקניית זכויות קנייניות. אולם, יש בה כדי לבסס קיומה של הסכמה מכללא כאמור. הסכמה זו מקימה לנתבע רשות שימוש, כזכות אישית, אשר ניתן להפסיקה בכל עת על ידי המעניק אותה, בודאי כאשר מדובר ברשות שימוש ללא תמורה - "רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להמשיכה. זו היא רשות חינוך המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני" (פרופ' נ. זלצמן רשיון במקרקעין, הפרקליט מב 24, 57; וראה גם מ. דויטש, קניין כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

משהוגשה התובענה דנן, ועוד קודם לכן במסגרת האסיפה הכללית מיום 30.05.12 (נספח יב' לתצהיר גותי), הביעו בבירור בעלי הדירות את רצונם להפסקת השימוש על ידי הנתבע (מיגל דויטש קניין (תשנ"ט, כרך ב') עמ' 414, רע"א 6339/97 ווקר ואח' נ' סלומון ואח' פד"י נח (1) 199 וע"א (ת"א) 2816/03 ציפורה קונצ'צקי ואח' נ. דליה שפלן ואח' תק-מח 2006 (2), 991). ויודגש, רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 צידיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)).

במקרה דנן לא קמות הנסיבות המיוחדות המצדיקות הכרה בקיומה של רשות שימוש בלתי הדירה של הנתבע ברחבה.

ראשית, לא נטענה, וממילא לא הוכחה, תמורה כלשהי שניתנה לבעלי הדירות בגין השימוש (תשלום עבור החזקת הרחבה כמפורט בפסק הדין לעיל אינו יכול להיחשב כתשלום כזה וממילא גם על פי שיטת הנתבע המדובר בתשלום חלף מיסי נציגות בלבד). ויעזר, טענה בנוגע לתמורה כאמור גם לא מועלית ע"י הגב' ירושלמי בנוגע לתקופת החזקה של כהן בחנות.

שנית, לא הוכחה השקעה משמעותית של הנתבע ברחבה (לבד מהדבקת ריצוף). ויודגש, מדובר בסגירת הרחבה בריעות שהסרתן קלה באופן יחסי וממילא ללא כל פגיעה בגוף החנות או באפשרות השימוש בחנות עצמה כיחידה נפרדת.

שלישית, לא הוכחה צפיה לגיטימית של הנתבע להמשך השימוש - אף שהנתבע ידע כי הרחבה איננה חלק מהחנות עת שכר אותה לראשונה, הוא לא טרח לוודא קיומה של הסכמה פוזיטיבית לשימוש ברחבה, שממילא גם לא היתה קיימת כאמור (עמוד 27 שורות 1-2). הוא גם לא טרח לקבוע באופן פוזיטיבי את זכויות השימוש כשרכש את החנות שנים מאוחר יותר.

רביעית, הוכח גם כי השימוש ברחבה הנעשה כיום אינו זהה לזה אשר נעשה לפני שנים, ודאי שלא בתקופת הבעלים הקודם. מדובר בשימוש הולך ומעצים על פי עדות הגב' גותי "השימוש משנת '85 הוא לא כמו מה שהיה לפני '85. ש.ת. לא היו יריעות, לא היו כסאות ושולחנות וגם לא היה וידיאומט בכניסה. ש.ת. אני לא ידעתי שהוא שוכר את החנות. ראיתי אותו וקיבלתי אותו כאחד הדיירים. ש.ת. לא היו שולחנות כסאות אצל כהן. ש.ת. היו מביאים כסאות ולוקחים חזרה. לא היה קבוע. היינו יושבים גם על המעקה מסביב" (עמוד 12 שורות 22-26). כך גם עולה מעדות הגב' ירושלמי (עמוד 22 שורות 18-21 ושורות 26-27 ועמוד 23 שורות 12-16) בהשוואה לעדות הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(עמוד 24 שורות 26-29) - בעוד שבעבר הופעל במקום "קיוסק", היום מדובר ב"בית קפה וגם לאלכוהול".

די בכך כדי להצדיק את זכות בעלי הדירות להפסיק את רשות השימוש מכללא.

עקרון תום הלב אומנם חולש על כל תחומי המשפט, לרבות, במערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (2896/90 טרזקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454, ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז (4) 737 ורע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פד"י נח (1) 199). אולם, במקרה דנן לא מצאתי כל חוסר תום לב בהתנהלות התובעים או בסעדים המבוקשים על ידם - אף אם ניתן ללמוד על קיומה של הסכמה לאורך השנים הרי שזו ניתנת להפסקה בכל עת בכפוף להודעה. קבלת טענה כאילו חזרה מהסכמה (הנלמדת מכללא בשל שתיקה לאורך שנים) לשימוש ברכוש המשותף כמוהה כהתנהגות בחוסר תום לב, משמעה הפיכתה של כל רשות שימוש, ללא כל קשר לדרך שבה ניתנה, לבלתי הדירה. אין הדבר יכול לעמוד.

לאור רשות השימוש מכללא כאמור מוצא אני לנכון לדחות את התביעה לחיוב הנתבע בתשלום דמי שימוש ראויים בגין התקופה שעד מועד הגשת התביעה.

ראשית, לא עלה בידי התובעים להוכיח נזק ממון ישיר המזכה בפיצוי בגין הסגת גבול בהתאם להוראות סעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. בהקשר זה לא הוכח כל הפסד ממון כתוצאה מן השימוש שבוצע על ידי הנתבע.

שנית, התובעת לא פירטה כנדרש את עילת תביעתה בהקשר זה ובכלל האמור גם לא שולמה אגרה בגין עילת תביעה זו. אין בעל דין יכול לעתור למתן סעד כספי מבלי לכמת את הסעד הנתבע על ידו ואין הוא יכול לצאת ידי חובתו בבקשה לחיוב כספי על פי קביעת שמאי מטעם בית המשפט. על התובע הנטל להציף את גדר המחלוקת במסגרת כתב התביעה, לרבות הסעדים הנטענים, ולהוכיח את מכלול טענותיו והסעדים הנתבעים. את זאת לא עשתה התובעת.

אעיר כי גם אין מקום למתן היתר לפיצול סעדים בהקשר זה שעה שתביעה לחיוב בדמי שימוש ראויים בנסיבות דנן מצויה בגדר סמכותי העניינית (ר' 285/10 נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפריר (פורסם בנבו ביום 18.01.11)). התובעת יכולה היתה להוכיח תביעתה כדין במסגרת ההליך דנן ואין לאפשר לה "מקצה שיפורים" על ידי מתן היתר לפיצול סעדים כמבוקש.

שלישית, משהוכרה רשות שימוש מכללא שניתנה לנתבע על ידי בעלי הדירות ונדחתה טענת הנתבע בדבר היות אותה רשות שימוש בלתי הדירה, בין היתר, לאור העובדה כי לא ניתנה כל תמורה בגין שימוש זה, לא ניתן להפוך עתה את היווצרות בדיעבד ולחייב במתן תמורה ראויה עבור שימוש הדיר שהוסכם מכללא לתיתו בחינם. חיוב בתשלום דמי שימוש יביא לתוצאה לפיה על אף שניתנה רשות שימוש חינם לנתבע וזו הופסקה על פי דרישה (בהגשת ההליך דנן), תהפוך רשות שימוש זו, רטרואקטיבית, לרשות שימוש בתשלום. הדבר יעקר מתוכן את בסיס חיוב הנתבע בסילוק ידו מן הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפני סיום אתייחס בקצרה לשתי טענות נוספות שהעלה הנתבע.

אין כל משמעות לטענות התכנוניות על ההכרעה הקניינית שבהליך זה - דיני התכנון אינם משפיעים על הזכויות הקנייניות בנכס. כשם שהיתר בניה להרחבת דירה אין בו די כדי לגבש זכויות קנייניות לבצע את אותה הרחבה (ללא הסכמת בעלי הדירות הנדרשת על פי הדין), כך אין היתר תכנוני לשימוש או היתר לסגירה או רישיון עסק מגדירים את הזכות הקניינית לבצע שימוש ברכוש משותף (ר' ע"א 2527/08 (ת"א) ענבר נורית פולק ואח' נ' עו"ד מני בן מאור ואח' (פורסם בנבו) וכן תיק 285/10 נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפריר (פורסם בנבו ביום 08.12.11)).

בנסיבות דנן ממילא הטענות התכנוניות גם לא הוכחו כנדרש – לא ניתן לבסס כל ממצא על התשריטים בנספח ב' לתצהיר הנתבע - לא ברור מקורם של תשריטים אלו, לא הוגשו העתקים מלאים שלהם, לא העתקים רשמיים ואף לא המקור. גם היתר הבניה שהוצג (נספח ג' לתצהיר), לבד מכך שהוצג באופן חלקי ולא בהתאם לנדרש בפקודת הראיות על ידי נציג רשמי של עיריית רמת גן, הרי שלא ניתן ללמוד ממנו דבר בנוגע לזכויות הקנייניות ברחבה או בנוגע להיתר השימוש על ידי בעלי הדירות. אין אפילו עדות כי המדובר בהיתר רלבנטי (עמוד 28 שורות 2-3). כנ"ל אמורים הדברים גם לגבי תעודת הגמר ורישיון העסק שצורפו לתצהיר (נספחים ד' ו-ה' בהתאמה).

טענת הנתבע כי התובענה בנוגע לשימוש ברחבה התיישנה אין לה על מה שתסמוך.

משנקבע כי שימוש הנתבע ברחבה לאורך השנים נעשה על פי הסכמה מכללא של בעלי הדירות כאמור הרי שעילת התביעה לסילוק ידו של הנתבע מהרחבה האמורה נולדת רק מיום בו הוחלט על הפסקת רשות השימוש, קרי, החלטת האסיפה הכללית מיום 30.05.12 (נספח יב לתצהיר גותי). כל פרשנות אחרת משמעה, למעשה, מתן זכות בלתי הדירה גם מקום שזו לא הוקנתה.

אף אם תאמר כי הנתבע החזיק ברחבה ללא הסכמת בעלי הדירות הרי שגם אז התובענה לא התיישנה - הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת" המקימה לבעלי הדירות, בכל יום בו הנתבע ממשיך להחזיק ברחבה, עילת תביעה מתחדשת (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם).

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומורה כלהלן:

1. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 6,140 ₪ לסילוק חובות מיסי נציגות עד לחודש 12/12 כולל.

לסך החוב הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מתום כל שנה (בגין החוב המפורט לאותה שנה בנספח יג' לתצהיר גותי) ועד למועד הגשת כתב התביעה, 12.11.12.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 572/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

החל ממועד הגשת כתב התביעה כאמור ועד למועד התשלום בפועל יתווספו לסכומים הפרשי הצמדה וריבית כדין.

2. אני מורה לנתבע לסלק את ידו מהרחבה ובכלל האמור לסלק את השולחנות והכיסאות המוצבים במקום, היריעות, השילוט ומערכת התאורה.

נאסר בזה על הנתבע ו/או כל מי מטעמו לסגור את הרחבה באמצעות יריעות ו/או בכל אמצעי אחר ו/או להתקין כל מתקן ברחבה ללא קבלת אישור האסיפה הכללית.

נאסר בזה על הנתבע להניח שולחנות וכסאות ברחבה באופן קבוע.

3. בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בספרי המקרקעין על זכויות הנתבע בגוש 6205 חלקה 451 תת חלקה 1 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 572/12 בדבר שימוש ברחבת הרכוש המשותף".

4. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות אגרת ההליך, סך של 745 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 12.11.12, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות ניהול ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, סך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו בתיק 3 דיונים, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ו' טבת תשע"ד, 09 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב